CÓDIGO TRIBUTARIO – ART. 4° BIS, ART. 4° TER, ART. 4° QUÁTER, ART 26° BIS, ART. 64°

(ORD. N° 382, DE 14.02.2025)

Consulta sobre la aplicación o no de los Artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter del Código Tributario o de alguna norma antielusión especial a los actos que describe en su presentación ya sea individualmente considerados o en su conjunto.

Se ha recibido en esta Dirección Nacional la presentación indicada en el antecedente, mediante la cual se solicita un pronunciamiento que confirme que a los actos que describe en su presentación no le son aplicables las normas de los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter del Código Tributario ni alguna norma especial antielusión, en particular, la norma del artículo 64 del Código Tributario.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, la familia XXXX se compone de 5 hermanos, cada uno es dueño del 20% de las acciones de Agrícola SpA, sociedad acogida al régimen tributario Pro-Pyme del artículo 14 letra D de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y del 20% de las acciones de Inversiones SpA, sociedad acogida al régimen del artículo 14 letra A de la LIR.

Todos los activos de Agrícola SpA son inmuebles que explota vía arriendo y plantación agrícola. Por su parte, Inversiones SpA, a pesar de dedicarse únicamente al giro señalado en su razón social, tiene entre sus activos cuotas de fondos de inversión e inmuebles.

Indica que para efectos de desarrollar el negocio de forma lógica y ordenar los activos de manera eficiente, así como también para generar un sistema de administración reglado entre los hermanos XXXX, se busca reorganizar ambas sociedades de modo de crear solo una sociedad propietaria de todos los inmuebles y que esta última sea administrada no por personas naturales –como ocurre actualmente– sino que por sociedades de cada hermano XXXX, aprovechando la sinergia para tener una estructura de holding familiar. La reorganización tiene como objetivos los siguientes:

- Construir una estructura holding familiar para que el patrimonio de la familia se mantenga unido, pero que al mismo tiempo pueda cada línea familiar administrar con mayor independencia.
- Participar en las sociedades de manera indirecta a través de una sociedad, en vez de que los miembros de la familia participen directamente como personas naturales.
- Separar las líneas de negocio de la familia, esto es, el negocio inmobiliario y agrícola respecto del financiero.
- Separar totalmente la participación accionaria de cada línea familiar, de manera tal que cada una de ellas tenga su propio vehículo de inversión y no queden participaciones recíprocas en las sociedades de otra línea familiar.

En virtud de dichos objetivos, se propone una reorganización que comprende los siguientes pasos:

(i) Aporte de inmueble: Inversiones SpA aportará el inmueble del que es propietaria a Agrícola SpA concentrando en esta la propiedad de los inmuebles. El aporte se realizará al valor tributario registrado en la contabilidad de Inversiones SpA. Tras el aporte, Inversiones SpA quedaría con el 95% de la participación social, y cada uno de los hermanos con el 1% restante.

(ii) Disminución de capital y retiro de accionistas: Agrícola SpA disminuirá su capital social, devolviendo a cada hermano el capital aportado junto con las utilidades que le correspondan, gatillándose la tributación asociada según los registros empresariales y el capital efectivamente aportado.

(iii) División: Inversiones SpA se dividirá en 5 sociedades por acciones, asignándose el patrimonio proporcional y equitativamente entre la sociedad original y las sociedades que nacen de la división, según el porcentaje de distribución de todas las cuentas patrimoniales. Cada una de las sociedades nacientes tendrá un costo tributario espejo, así como un 20% del total de los activos y pasivos de la sociedad cuya división les dio origen, siendo, por tanto, idénticas entre sí, tanto en el costo tributario de las acciones, como en sus activos, pasivos y patrimonio.

(iv) Permuta: Los hermanos se permutarán recíprocamente sus acciones en cada una de las sociedades naciente de la división quedando cada uno con el 100% de una sociedad por acciones.

En relación con lo expuesto, solicita confirmar que, por las razones expuestas, a los actos que componen la reorganización descrita, considerados individualmente y en su conjunto, no le son aplicables los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter del Código Tributario, ni alguna otra norma antielusión de carácter especial.

La consulta es realizada al amparo de lo dispuesto en artículo 26 bis del Código Tributario. Atendido el tenor de la presentación, se trata de una consulta no vinculante, de acuerdo con lo instruido en el resolutivo 1° de la Resolución Exenta N°112 de 2021, emitida por este Servicio.

II. ANÁLISIS

Antes de entrar al fondo del análisis cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 bis del Código Tributario, vigente a la fecha de la presente respuesta, y lo expuesto en la letra a. del resolutivo 1° de la Resolución Exenta N°112 de 2021 emitida por este Servicio, en caso de que se efectúe una consulta por una norma específica antielusiva, se debe señalar expresamente por el consultante la norma sobre la cual se consulta, limitándose la consulta y su respuesta a la norma específica de que se trate. En razón de lo anterior, si bien se solicita que este Servicio emita un pronunciamiento que confirme que a las operaciones descritas no le son aplicables ninguna norma antielusión de carácter especial, se emitirá un pronunciamiento únicamente en cuanto a la aplicación o no de la norma general antielusiva y en cuanto a la aplicación o no del artículo 64 del Código Tributario, que es la norma especial antielusiva a la que se refiere expresamente en el texto de su presentación.

Para efectos del presente análisis, se observarán cada una de los actos y negocios que componen la reorganización empresarial planteada por los consultantes, comprendiendo aspectos normativos relacionados a cada acto y, luego, aquellos relacionados a la norma general antielusiva.

(i) Aporte de inmueble a título de capital por parte de Inversiones SpA a Agrícola SpA

Si bien el artículo 64 del Código Tributario[1] faculta a este Servicio para tasar la base imponible de los impuestos en las circunstancias que señala, se establece en el inciso décimo de dicho artículo que no se aplicará la facultad de tasación respecto de cualquier tipo de reorganizaciones empresariales, tales como, la conversión del empresario individual o el aporte de activos de cualquier clase, realizados por personas naturales o jurídicas, asignados dentro del territorio nacional, en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocios; luego, el inciso undécimo establece como requisitos copulativos para que el Servicio de Impuestos Internos esté inhibido de tasar, que se mantenga el costo tributario de los activos en la sociedad que recibe el aporte y que no se originen flujos efectivos de dinero para el aportante.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso undécimo, cabe señalar, que se indica en la presentación que el aporte del inmueble por parte de Inversiones SpA a Agrícola SpA se realizará a valor tributario registrándose por la sociedad receptora a dicho valor y; que no se generarán flujos efectivos de dinero para el aportante.

Respecto de la legitima razón de negocios, el inciso décimo cuarto del artículo 64 del Código Tributario dispone que se entenderá por tal, entre otras, aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio, así como obtener ventajas competitivas; financiamiento; la eliminación o mitigación de costos o riesgos; aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado; optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas y que, en cualquier caso, sea distinta a la meramente tributaria.

Según se desprende, no se trata de una definición taxativa, pero que otorga certeza a los contribuyentes al entregar algunos parámetros o lineamientos para calificar cuándo una reorganización empresarial obedece

[1] El presente análisis se efectúa en base al artículo 64 del Código Tributario actualmente vigente, norma que fue modificada mediante la Ley N° 21.713.

a una legítima razón de negocios, correspondiendo al contribuyente acreditarlo con todos los medios probatorios pertinentes.

Luego, a partir de lo expuesto, se evidencia que la existencia de una legítima razón de negocios es una circunstancia de hecho, la cual deberá ser verificada en el correspondiente procedimiento de fiscalización, instancia en la cual deberá analizarse el conjunto de actos o contratos que conforman la reorganización pretendida, y no solo el aporte en cuestión, y que de concluirse que no existe tal legítima razón de negocios, se ejercería la facultad de tasación, que, en este caso, correspondería al aporte del inmueble por parte de Inversiones SpA.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, y teniendo en consideración lo dispuesto en el inciso décimo cuarto del artículo 64 del Código Tributario, los resultados o finalidades que se obtengan mediante el establecimiento de una sociedad como holding, separación de la participación accionaria por cada socio y la separación del negocio agrícola de las inversiones financieras, podrían calificar, en principio, como una legítima razón de negocios, la cual deberá ser, en todo caso, verificada en la correspondiente instancia de fiscalización.

(ii) Disminución de capital y retiro de accionistas de Agrícola SpA

La devolución del capital aportado por cada hermano junto con las utilidades que a cada uno les correspondan, deberá sujetarse al tratamiento tributario contemplado en los artículos 17 N° 7 y 14 de la LIR.

(iii) División

Como se indicó en el antecedente, Inversiones SpA se dividirá en 5 sociedades por acciones que serán idénticas entre sí tanto en sus activos, pasivos y patrimonio.

Desde el punto de vista normativo, cabe advertir que este Servicio ha señalado[2] que en la división no existe propiamente una transferencia o transmisión de bienes que constituya una enajenación, sino que una especificación de derechos preexistentes, los cuales quedan radicados en una entidad jurídica independiente. Consecuentemente con lo anterior, y de conformidad con los incisos noveno y undécimo del artículo 64 del Código Tributario, no se aplicará la facultad de tasación respecto de divisiones nacionales, siempre que se mantenga el costo tributario de los activos en la o las sociedades que nacen con ocasión de la división.

Por lo tanto, de cumplirse con el requisito de que los activos se mantengan registrados a valores tributarios, tal cual se indica en su presentación, este Servicio se encontraría inhibido de ejercer la facultad de tasación respecto de la división.

(iv) Permuta

Se indica en la presentación que el valor por el cual los hermanos se permutarán las acciones entre sí coincidirá con su valor de adquisición, el cual es idéntico para cada uno de ellos, por lo que sostiene que no debería producirse cambio alguno en el patrimonio de los accionistas, traduciéndose la permuta en una mera relación de sustitución o reemplazo. Agrega, que el activo que subyace a las 5 sociedades quedadas luego de la división precedente son acciones que tienen el mismo valor de mercado y que corresponden a las acciones de Agrícola SpA.

Sobre lo anterior, este Servicio señaló lo siguiente[3]:

a) Lo que determina la existencia de un mayor o menor valor en la permuta es la comparación entre el costo tributario de los bienes que cada permutante enajena y el precio de los bienes que cada permutante recibe a cambio, que corresponde al valor asignado por las partes en la permuta[4].

b) Si la permuta de acciones se traduce, atendidas las condiciones en que tiene lugar, en una mera relación de sustitución o reemplazo, el justo precio de las acciones que se permutan estará determinado por el valor de mercado que dichas acciones tuvieron para cada permutante, el que a

[2] Oficio Nº 1264 de 2020.
[3] Oficio N° 2574 de 2021.
[4] En el mismo sentido Oficios N° 1264 de 2020, N° 1065 de 2020 y N° 3422 de 2016.

su turno determinará el valor al que deben reconocerse las acciones que cada permutante recibe a cambio producto de la permuta[5]. Dicho valor de mercado se analizará *"considerando específicamente las circunstancias que rodean la operación, en este caso, sociedades espejo con el mismo valor para los permutantes"*[6].

Esta misma idea es reconocida en el inciso segundo del artículo 64 del Código Tributario el cual, al referirse a qué debe entenderse por valores normales de mercado, dispone que se debe considerar *"cualquier otra operación que se analice y, en general, cualquier otra circunstancia relevante"*. Conforme con lo señalado, considerando las circunstancias que rodean la operación, esto es, que se trata de sociedades espejos que nacen de una división con el mismo valor para los permutantes, con idéntico activo subyacente y en la que no se pretende liquidar los activos de la sociedad dividida entre sus accionistas sino que, separar la participación accionaria de cada línea familiar; el valor de mercado de las acciones que se permutan estará determinado por el costo que dichas acciones tuvieron para cada permutante el que a su turno determinará el valor al que deben reconocerse las acciones que cada permutante recibe a cambio producto de la permuta.

c) En caso de que la permuta se traduzca efectivamente en una mera relación de sustitución o reemplazo, no será aplicable la facultad de tasación establecida en el artículo 64 del Código Tributario, por cuanto el resultado de la enajenación producida con ocasión de la permuta será neutro desde el punto de vista tributario al no incidir en la determinación de un impuesto. En efecto, que el precio deba incidir en la determinación de un impuesto es un requisito que exige el inciso primero del artículo 64 al prescribir *"cuando el precio o valor asignado al objeto de un acto, convención u operación sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio podrá tasar (…)"*.

d) La verificación de la referida neutralidad deberá efectuarse en la respectiva instancia de fiscalización. Por lo tanto, corresponderá a los contribuyentes, en dicha oportunidad, acreditar la concurrencia de las circunstancias descritas en su presentación.

Análisis de la reorganización empresarial en el marco de la norma general anti elusiva

Analizados los actos que conforman la reorganización empresarial expuesta por la contribuyente, corresponde determinar, en el contexto de la norma general antielusiva, si aquellos actos en su conjunto cumplen con los objetivos declarados por el solicitante y si estos obedecen a razones económicas y jurídicas distintas a las meramente tributarias.

Al respecto, este Servicio ha señalado[7] que la legislación nacional cautela el legítimo derecho de los contribuyentes a organizar sus actividades, actos o negocios afectados con impuestos de la forma en que la autonomía de la voluntad y la libertad contractual lo permitan, considerando además que no toda ventaja tributaria, lograda por el contribuyente, constituye elusión, sino que para ello es indispensable que haya un abuso de las formas jurídicas o la realización de actos simulados que atentan contra los hechos gravados previstos por el legislador tributario.

Considerando lo anterior, en base a lo expuesto por los consultantes, en principio no se observa que las operaciones configuren una hipótesis de abuso de las formas jurídicas, en los términos del artículo 4° ter del Código Tributario. Según lo planteado en la consulta, mediante el conjunto de actos que involucra la reorganización, se buscarían como resultados o efectos separar el negocio inmobiliario y agrícola respecto del financiero; establecer a Inversiones SpA como holding del grupo; y, separar la participación accionaria de cada línea familiar. En principio, los resultados pretendidos declarados en la consulta guardarían coherencia con los efectos que produciría la ejecución del conjunto de actos que se propone.

En efecto, Inversiones SpA se desprendería de sus inmuebles aportándolos a Agrícola SpA quedando esta como propietaria de todos los inmuebles; tras la disminución de capital y retiro de los hermanos, se posicionaría Inversiones SpA como holding del grupo empresarial-familiar; y, tras la división de tal holding

[5] En el mismo sentido Oficio N° 4360 de 1999.
[6] Según se indica en nota al pie N° 5 del Oficio N° 2574 de 2021.
[7] Circular N° 65 de 2015.

y posterior permuta, cada hermano será propietario en un 100% de un vehículo de inversión mediante el cual mantendrá la propiedad sobre el negocio familiar, sin que existan participaciones recíprocas.

Lo anterior generaría eficiencias en la administración, así como una mayor independencia en el manejo de inversiones por cada línea familiar y permitiría, por ejemplo, evitar eventuales desavenencias que podrían generarse con los herederos a la muerte de alguno de los hermanos.

Por otra parte, el artículo 4º quáter del Código Tributario, dispone que existe simulación, para efectos tributarios, cuando los actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento o se simulen actos o negocios jurídicos para acceder a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.

En este caso, no se aprecia a priori que la reorganización empresarial proyectada pudiera configurar simulación, por cuanto, de acuerdo con lo expuesto por la consultante, la totalidad de los actos que se pretenden ejecutar guardaría coherencia económica y legal, sin que sea posible observar que se oculta o disimula la configuración de un hecho gravado; la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria; o, su verdadero monto o data de nacimiento o simular actos o negocios jurídicos para acceder a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial; sin perjuicio que ello deberá verificarse en la respectiva instancia de fiscalización.

En razón de lo anterior, las operaciones expuestas no constituirían actos o negocios que puedan ser considerados elusivos en los términos dispuestos en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, lo que no obsta a que las circunstancias concretas del caso –no informadas en la presentación– puedan modificar tal conclusión.

En este sentido, ante un escenario de fiscalización por parte del Servicio, se verificará, por ejemplo, si en virtud de la reorganización se produce un traspaso patrimonial entre los hermanos respecto del que se evite la tributación correspondiente de conformidad con la ley; los eventuales efectos patrimoniales tras el aporte de los inmuebles considerando la participación de los hermanos, aportes previos, modificaciones sociales, y valor tributario de los inmuebles; que el inmueble aportado por Inversiones SpA no haya sido enajenado por Agrícola SpA de suerte tal que atendidas las circunstancias concretas del caso pueda concluirse que el principal efecto del aporte fuera acoger la enajenación a un régimen tributario más favorable; forma de pago de la disminución de capital y si se paga en especies, la valoración dada a dichos bienes, entre otros.

III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto en el Análisis, se concluye que:

1) De cumplirse con los requisitos contemplados en el artículo 64 del Código Tributario, este Servicio se encontraría inhibido de ejercer la facultad de tasación sobre los aportes y división. En particular, y respecto a los aportes de los inmuebles, en principio la reorganización –en los términos expuestos– podría responder a una legítima razón de negocios, circunstancia que deberá verificarse en la respectiva instancia de fiscalización frente a las circunstancias concretas del caso. Asimismo, respecto de la permuta de acciones, no será aplicable la facultad de tasación del artículo 64 ya referido, siempre que dicha operación se traduzca efectivamente en una mera relación de sustitución o reemplazo.
2) De conformidad a lo expuesto en el Análisis, el conjunto de actos que describe en su consulta no constituiría, en principio, una actuación elusiva en los términos dispuestos en los artículos 4° bis, ter y quáter del Código Tributario, lo que no obsta a que las circunstancias concretas del caso –que no fueron especificadas en la consulta– puedan modificar la conclusión anterior.

SIMÓN RAMÍREZ GUERRA
DIRECTOR (S)

Oficio Ordinario N° 382, de 14.02.2025
Subdirección de Fiscalización
Depto. de Análisis de la Elusión